

1503071-44.2019.8.26.0268

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Decorrente de Violência Doméstica

Magistrado: TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... sustenta que o réu teria sido o autor da tentativa de roubo baseada em dois fatos: i) as contradições do réu, referentes à sua participação no roubo ocorrido no dia 15 de janeiro; ii) o reconhecimento realizado pelas vítimas do presente roubo em solo policial, posteriormente repetido em juízo.

Ocorre que, como ficará demonstrado, nenhuma das duas provas é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

1ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra-SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503071-44.2019.8.26.0268 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503071-44.2019.8.26.0268

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Decorrente de Violência Doméstica

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, 2033758/2019 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 3487010 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 149/19/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2033758 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 149/19/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2033758 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 149/19/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2033758 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 149/19/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 2033758 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA, 149/19/406 - DEL.POL.ITAPECERICA DA SERRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON MENDES MARQUES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). TALES NOVAES FRANCIS DICLER

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ofereceu denúncia contra JEFFERSON MENDES MARQUES DA SILVA, imputando-lhe a conduta descrita art.157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal c.c art. 14, inciso II, do mesmo diploma legal, e no art. 15 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal.

Segundo a denúncia:

(1) No dia 14 de janeiro de 2019, por volta das 23h20min, na Estrada Romualdo Crem, nº 50, bairro Potuverá, nessa cidade e Comarca, o denunciado, agindo em concurso e unidade de desígnios com outro indivíduo ainda não identificado, tentou subtrair, para proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida por meio do emprego de arma de fogo, bens pertencentes às vítimas Eliziana Aparecida Santos Aleixo e Denilson Aleixo Maciel, conforme boletim de ocorrência de fls. 03/04.

(2) Ainda, nas mesmas circunstâncias, o denunciado disparou arma de fogo em lugar habitado em via pública.

A denúncia foi recebida às fls. 94-96, determinando-se a citação do réu para apresentação de resposta à acusação.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação às fls. 122.

Em primeira audiência, o recebimento da denúncia foi ratificado e foram ouvidas as testemunhas de acusação (fls. 149-150).

Em nova audiência, foram ouvidas as vítimas, testemunhas de defesa e interrogado o réu.

O Ministério Público pediu a parcial procedência ação, com a condenação nos termos da denúncia em relação ao crime de roubo tentado, e absolvição quanto crime de disparo de arma de fogo (fls. 246-253).

A defesa, por sua vez, pleiteou a absolvição, alegando que o reconhecimento feito pelas vítimas em delegacia não seguiu os trâmites previstos em lei e que, assim, não há provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da primariedade do réu e que lhe seja concedida oportunidade de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

O artigo 157 do Código Penal assim descreve o delito de roubo:

Roubo

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

[...]

§2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

[...]

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

A materialidade do delito está comprovada pelos boletins de ocorrência de fls. 3-7, auto de exibição e apreensão de fl. 14, e pela prova oral colhida ao longo da instrução.

Por outro lado, entendo que não foram produzidas provas suficientes para comprovar a autoria.

Vejamos a prova oral colhida.

A vítima Eliziana Aparecida Santos Aleixo disse em juízo que estava voltando para sua casa no Recanto Bela Vista, e quando entrou na rua da entrada percebeu que havia um carro atrás de si, que a ultrapassou em alta velocidade e seguiu. A vítima continuou subindo pela rua e quando estava próximo à uma estação de carga o carro que havia passado por ela, havia manobrado e vindo em sentido oposto, momento no qual acendeu os faróis e veio para cima do carro da vítima, que jogou o carro para cima do veículo dos assaltantes, desviou e fugiu, ouvindo dois tiros posteriormente. Embora desesperada, seguiu com o carro até a portaria de seu condomínio em alta velocidade e ali chegando o pessoal da escolta do condomínio foi atrás do carro. Após, ao ver as imagens da câmera de segurança juntamente com a polícia conseguiram ver a placa do carro. Ressaltou que viu o rosto do motorista quando ele acendeu o farol. Após o roubo ficou na casa de seus pais em Barueri,

sendo que dois a três dias depois foi até a delegacia para finalizar a ocorrência. Acredita que o reconhecimento tenha sido feito depois, não foi no mesmo dia da ocorrência. Os policiais não disseram como encontraram o réu. Na delegacia o reconhecimento foi feito por álbum de fotos. Soube que outra advogada da comarca havia passado pela mesma situação. Ficaram sabendo que os réus tiveram acesso à uma lista de advogadas. Na delegacia foi apresentado um álbum físico de fotos. Não viu quem disparou a arma de fogo. Havia ao menos duas pessoas do carro, o réu era o motorista. Que ficou sabendo que outros advogados foram vítimas já na delegacia, em uma das duas vezes que compareceram lá.

A vítima Denilson Aleixo Maciel disse em juízo que estava voltando a noite para sua casa, enquanto a esposa guiava o veículo por uma rua de terra. Notaram um veículo Logan Prata atrás do automóvel que guiavam, tendo realizado a ultrapassagem em alta velocidade e seguido. Pouco depois, o veículo veio na direção contrária e acendeu os faróis altos, vindo para cima do carro guiado pelas vítimas. Quando um carro ficou de frente para o outro o veículo guiado pelo réu acendeu os faróis, momento em que o depoente pode ver o acusado e uma outra pessoa. A esposa do declarante jogou o veículo para cima do carro que vinha no sentido contrário, e conseguiu desviar, seguindo em alta velocidade até o condomínio. Enquanto a esposa do declarante seguia com o carro em alta velocidade o depoente ligou para o condomínio, que abriu as portas e ficou com a escolta na frente. O depoente disse ter ouvido dois disparos de arma de fogo, mas não viu quem disparou. Relatou que foram delegacia e foram informados pelo escrivão ou delegado que havia outras vítimas advogadas de crimes semelhantes. Cerca de três dias depois voltaram a delegacia, foi exibido um álbum com fotografias e reconheceu o réu. Reiterou que quando estava chegando próximo do condomínio, há uma estação férrea, e o Logan acendeu o farol alto e pode visualizar o motorista. Quando chegou no condomínio as portas estavam abertas, mas a escolta ainda não havia chegado.

Ambas as vítimas, ao verem o réu na audiência virtual, confirmaram que ele seria o motorista do veículo que os tentou abordar.

O policial civil Antônio Bernardo disse em juízo que a vítima lhe contou que estava voltando para casa, momento em que um veículo Logan se aproximou e ela, com medo, entrou em um condomínio, enquanto o réu efetuou dois disparos. Não sabe dizer se a vítima conhecia o réu. Sabe que ela entrou no condomínio com um veículo, o réu não conseguiu entrar, efetuou dois disparos e se evadiu. Segundo a vítima lhe relatou, era o próprio réu quem guiava o veículo e efetuou os disparos. Disse que a vítima falou que eram duas pessoas, tendo reconhecido uma e não a outra. Contou que a polícia chegou até o réu pois dois dias após os fatos apurados no presente procedimento, tentaram roubar a casa de uma advogada, em 4 assaltantes, sendo que as imagens de câmera de segurança mostraram que o réu ficou sozinho no carro. Ao mesmo tempo, o próprio réu teria ido à delegacia e falado que foi vítima de um sequestro e obrigado a participar do roubo na casa. As imagens foram mostradas à vítima do presente processo e ela reconheceu. O carro não foi localizado. Disse que o réu era especialista em roubar casa de advogadas e que no roubo da casa da Doutora Ana Paula foram encontrados objetos na casa do réu, dentre eles dois relógios. Contou que o reconhecimento fotográfico foi feito através de uma foto tirada na delegacia quando o réu foi até a delegacia, e essa foto foi mostrada para a vítima, que reconheceu prontamente. A vítima lembrou-se do cavanhaque. Foram apresentadas outras fotos de pessoas parecidas e a vítima reconheceu o réu. As fotos foram tiradas no celular de um colega de polícia, imprimidas e mostradas, de maneira apartada.

O policial civil Pedro Paulo Basseti disse em juízo que um dia o réu foi até o plantão da delegacia para registrar uma ocorrência, dizendo que havia sido vítima de roubo, mas a história era estranha, dizia que o carro era de Uber, que quatro indivíduos teriam praticado um roubo e ficaram rodando com ele na cidade por horas enquanto monitoravam uma vítima que iriam roubar a residência. Disse que foi feito de refém e ficou dirigindo o veículo, até que passaram a seguir a vítima e quando lá chegaram aproveitaram o momento em que ela abriu o portão e iniciaram o roubo. Disse que 3 assaltantes desembarcaram e um ficou no carro. Ocorre que as câmeras de segurança da casa mostraram que na verdade o motorista não era refém, e sim

comparsa, pois ninguém ficou no veículo restringindo sua liberdade, ele ficou sozinho. Diante disso os policiais desconfiaram e ao saber que o réu tinha um veículo Logan, lembraram da presente ocorrência. Que no dia que o réu foi até a delegacia fazer o B0 tiraram uma foto dele para mostrar para a vítima. Sobre o presente caso, disse que a vítima foi até a delegacia e informou que estava voltando para casa com o marido quando um veículo Logan cortou seu caminho e apontou uma arma, momento em que a vítima entrou em um condomínio e ouviu os disparos de arma de fogo. A quadrilha do réu era especialista em roubar advogados. Pelo que a vítima disse havia alguém no banco do passageiro. O veículo Logan foi recuperado após ser abandonado próximo ao Hospital Geral. Não se recorda se o veículo foi mostrado para a vítima, mas o tipo do carro e a cor batiam com as características passadas. Que parte da quadrilha foi presa em Embu Guaçu, mas é uma quadrilha grande e a testemunha não sabe dizer sobre as investigações, não sabe se o réu foi identificado pelos outros integrantes da quadrilha.

A testemunha de defesa Renato Marques Martinez disse que conhece o réu há mais de 15 anos, sendo que ele presta serviços para a empresa do declarante. Disse que o réu é técnico em TI, faz instalação de infraestrutura e servidores, costuma transportar equipamentos de alto valor. Disse nada saber que possa desabonar a conduta do réu. Contou que na época dos fatos o réu já prestava serviços. Disse que na época o réu contou que sofreu assalto enquanto fazia serviço de Uber, disse na época foi rendido, colocado em um porta-malas, algo assim.

A testemunha Leandro Dias da Silva disse em juízo que é amigo do réu há mais de 7 ou 8 anos, sendo inquilino da mãe dele. Disse que o réu trabalhava de UBER, nada sabendo que possa o desabonar. Relatou saber que ele tinha sido roubado, tendo o encontrado bem abalado, mas passou por alto, não deu detalhes. Disse que quando o encontrou percebeu que o réu estava tremendo, bem assustado, mas não estava machucado fisicamente.

O réu Jefferson Mendes Marques da Silva, em juízo, disse que as acusações são falsas. Contou que no dia 14 saiu para trabalhar, voltou para casa de sua mãe, por volta das 22h voltou para sua casa e ficou lá o resto da noite. No dia seguinte saiu para comprar uma pizza por volta das 22h e quando estava parado no farol adentraram seu carro e foi rendido, os bandidos o obrigaram a rodar pela cidade até chegar na casa de uma pessoa, no local um indivíduo ficou com ele no carro e outros desceram. O rapaz que ficou com ele no carro pediu para ir embora, sentido BR, até um local que foi colocado no porta-malas, rodou um pouco mais, e foi deixado no Branca Flor. Ligou para a polícia, foi informado para ir até a polícia civil, mas quando chegou lá a delegacia estava fechada. Voltou para o centro, foi até a base da GCM que indicou para fazer a denúncia no 190. Assim foi feito e voltou para casa. No dia 16 ligaram de novo falando que haviam achado o carro, retirou o carro do local e foi até a delegacia, ficou esperando a elaboração da ocorrência. Antes mesmo de dar depoimento foi colocado numa sala, quando foi ofendido, xingado de ladrão, policial disse que finalmente haviam o encontrado. Foram-lhe mostradas diversas fotos de muitas pessoas, falando que ele participava de uma quadrilha, passaram a discutir. Disse que falou ao policial que nunca roubou ninguém, reiterou que trabalhou desde pequeno. Disse que ficou cerca de 4 horas na delegacia, deu vários depoimentos, foi liberado e nem sabia que estava sendo investigado. Sobre o sequestro que sofreu, no dia 15, disse que estava num farol, quando 4 pessoas entraram em seu carro. Foram até o Rei do Boi, pararam lá e ficaram conversando no telefone com outras pessoas, falavam para o réu só olhar para frente. Todos estavam com capuz de blusa, mas nada na cara. Quando uma Fiat Toro desceu mandaram ele seguir, e ao chegar na frente da casa da pessoa pararam, três desceram e um ficou para fora do carro. Não sabe dizer se eram 5 ou 4 assaltantes. Reitera que um ficou o tempo inteiro dentro do carro, sendo que esse mandou ele descer sentido BR, e ao chegar na metade do caminho, mandou parar, colocou no porta-malas, e ficou andando por bastante tempo, até largar no Branca Flor. O carro foi encontrado no Branca Flor, no meio do mato. Disse novamente que no dia 14 saiu de sua casa, trabalhou cerca de 2 horas, ficou na casa de sua mãe na Vila Mariana, e às 22h voltou em Itapecerica, onde morava com Leandro.

Disse que no mesmo dia que foi roubado ligou de madrugada para a polícia. Quando

volta de SP pega a avenida JK, depois Francisco Morato, chega na BR e vem até Itapecerica. Não conhece as vítimas, nunca as viu. Disse aos policiais que o veículo era alugado e possuía monitoramento, mas eles jamais demonstraram interesse em buscar o monitoramento. Contou que o policial que tirou sua foto foi o mesmo que o acusava, e disse que ia tirar uma foto para mandar no grupo dos policiais para ver se alguém o conhecia. O veículo possuía insulfilm inclusive na parte frontal. Que saiba só foi acusado de roubo em dois processos, o presente e o da Fiat Toro. Que tira cerca de 6 ou 7 mil reais como Uber, trabalha também com TI e possui um imóvel que aluga.

Pois bem.

Em síntese, a versão acusatória sustenta que o réu teria sido o autor da tentativa de roubo baseada em dois fatos: i) as contradições do réu, referentes à sua participação no roubo ocorrido no dia 15 de janeiro; ii) o reconhecimento realizado pelas vítimas do presente roubo em solo policial, posteriormente repetido em juízo. Ocorre que, como ficará demonstrado, nenhuma das duas provas é suficiente para atestar, com a certeza necessária para uma condenação, que o réu estava envolvido na tentativa de roubo ora apurada.

De início, passemos às alegadas contradições relativas ao roubo do dia 15 de janeiro, que teve como vítima a advogada Ana Paula de Moraes, ocorrido um dia depois do roubo apurado no presente processo.

O réu assevera que no dia 15 de janeiro de 2021, por volta das 22h, estava em seu veículo Renault Logan Prata em Itapecerica da Serra quando foi abordado por ao menos quatro homens que o renderam e o fizeram dirigir até um bar. Lá, após vigiar uma pessoa, aguardaram que ela entrasse em um Fiat Toro e a seguiram até sua residência. Em frente à casa desta vítima, três pessoas desceram do veículo e entraram pelo portão, realizando o assalto, e um quarto indivíduo desceu e ficou do lado de fora, sendo que um quinto elemento teria ficado no interior do veículo, mantendo o réu sob ameaça. Contou não saber ao certo se eram 4 ou 5 pessoas. Diz o réu que o indivíduo ordenou que fosse embora sentido BR, onde acabou sendo abandonado ao final. Relata ainda que após diversas tentativas, conseguiu formalizar a ocorrência e no dia seguinte foi até a delegacia, momento em que passou a ser confrontado pelos policiais, que o acusaram de integrar uma quadrilha especializada em assalto contra advogadas.

Na versão apresentada pelos policiais e pela acusação, a história do réu não se sustentaria, afinal, as imagens da câmera de segurança da casa de Ana Paula mostram que, em realidade, 4 assaltantes desceram do veículo e ninguém ficou no interior do automóvel com o ora acusado, indicando que ele, em realidade, participava voluntariamente da empreitada criminosa. Ademais, haveria uma divergência de horários na história do réu, pois embora ele tenha afirmado ter sido “sequestrado” por volta das 22h, o boletim de ocorrência sobre o referido roubo na casa de Ana Paula indica que o delito teria ocorrido às 16h30.

Quanto ao horário do roubo, conquanto no boletim de ocorrência conste que o fato se deu por volta das 16h30, as próprias imagens referidas deixam claro que isso se trata de um erro material, afinal, é possível notar que já estava escuro no momento do delito, e as gravações indicam que tudo ocorreu por volta das 22h30 (fl. 30):

Considerando que desde o início o réu informou ter sido sequestrado por volta das 22h, o horário do roubo é ao menos compatível com a versão por ele apresentada, não havendo aqui qualquer contradição.

Já com relação à dinâmica do roubo, de fato, há algumas lacunas na história do acusado, sendo a maior delas a quantidade precisa de assaltantes que o teriam abordado. É certo que 4 pessoas desceram do veículo para assaltar a casa de Ana Paula, conforme fotos de fls. 28-34. Ocorre que, por tais imagens, não é possível dizer que mais ninguém ficou no veículo com o réu, e nem é possível assegurar que o indivíduo que desceu do carro, mas não entrou na casa, não tenha mantido o acusado sob ameaça, ainda que a certa distância, e depois novamente ingressado no veículo. Além disso, tais contradições deveriam ter sido apuradas na investigação relativa ao roubo que vitimou a advogada Ana Paula, e não agora. Chama a atenção que os policiais foram firmes ao dizer que desde o início estranharam a história do

acusado e rapidamente chegaram a conclusão de que ele participou do roubo a casa de Ana Paula de maneira voluntária.

Contudo, em consulta aos autos 1500027-80.2020.8.26.0268, no qual foi apurado o referido delito, é possível notar que em momento algum Jeferson foi investigado ou indiciado. Não há qualquer menção a ele naqueles autos, procedimento no qual certamente seria mais fácil apurar a participação do acusado, mesmo porque um dos assaltantes foi preso e inclusive confessou o delito. Porém, nem mesmo a íntegra das imagens da câmera de segurança, que poderia auxiliar à compreensão da dinâmica dos fatos, foi juntada, neste ou naqueles autos.

Além disso, o policial Antônio, ouvido no presente processo, disse que foram encontrados na casa do réu Jefferson objetos oriundos do roubo na casa de Ana Paula, incluindo dois relógios. Contudo, Jeferson não chegou a ser preso, não foi expedido mandado de busca e apreensão para sua casa, nada demonstra que qualquer objeto tenha sido apreendido consigo, sendo provável que o policial o tenha confundido com outra pessoa.

Percebe-se, portanto, que é incontroverso que Jefferson esteve presente no roubo da casa de Ana Paula, ocorrido no dia 15, seja como vítima ou como coautor. Contudo, na investigação realizada sobre aquela ocorrência, nada foi produzido que pudesse dirimir a dúvida sobre sua atuação, sendo absolutamente impossível fazê-lo nos presentes autos.

Não bastasse, segundo o relato dos policiais, o réu faria parte de uma grande quadrilha de assaltantes responsável por roubos contra advogados na região, sendo que parte desta quadrilha teria inclusive sido presa recentemente. Contudo, não consta no caderno investigatório nem ao menos o nome de qualquer outro integrante da suposta organização criminosa, muito menos qualquer ligação entre eles e o réu. Não foram apreendidos ou periciados celulares que pudessem comprovar o envolvimento do réu com os crimes, nenhum criminoso foi ouvido e questionado sobre o envolvimento de Jefferson.

Não há, em realidade, nada que ligasse Jefferson ao roubo ora apurado, que não o fato de ele possuir um Logan prata, veículo comumente encontrado pelas ruas.

E essa possível ligação de Jefferson com o roubo agora investigado também poderia ter sido comprovada de outra forma. Isso porque a vítima Eliziana informou que após a tentativa de abordagem ocorrida na entrada de seu condomínio, observou, junto com a polícia, as imagens das câmeras de segurança e conseguiu identificar a placa do automóvel Logan. Porém, tais imagens não foram juntadas aos autos, e, em realidade, os policiais nem sequer confirmaram essa versão, dizendo apenas que decidiram mostrar a foto do réu Jeferson às vítimas pois ele também teria um Logan prata.

É certo que se tais imagens fossem juntadas e fosse possível identificar a placa do veículo, como a própria vítima afirmou ser possível, não haveria qualquer dúvida quanto à participação do réu nos dois assaltos, porém isso não aconteceu.

Assim, de maneira concreta, o que resta é o reconhecimento realizado pelas vítimas em solo policial.

Outrossim, disseram os policiais que após ouvir Jefferson relatar o sequestro que teria sofrido, tiraram sua foto com um celular, imprimiram a imagem e a colocaram junto com um álbum contendo outras pessoas, sendo que ambas as vítimas o teriam reconhecido prontamente como um dos assaltantes.

Sobre a confiabilidade dos reconhecimentos fotográficos, vale observar recente decisão do STJ, que assim entendeu:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INVALIDADE DA PROVA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA UNICAMENTE COM BASE EM RECONHECIMENTO EFETUADO PELA VÍTIMA. ABSOLVIÇÃO. HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

[...]

2. A jurisprudência desta Corte vinha entendendo que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRg no

AREsp n. 1.054.280/PE, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, DJe de 13/6/2017). Reconhecia-se, também, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, pode constituir meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

3. Recentemente, no entanto, a Sexta Turma desta Corte, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa".

4. Uma reflexão aprofundada sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, leva a concluir que, com efeito, o reconhecimento (fotográfico ou presencial) efetuado pela vítima, em sede inquisitorial, não constitui evidência segura da autoria do delito, dada a falibilidade da memória humana, que se sujeita aos efeitos tanto do esquecimento, quanto de emoções e de sugestões vindas de outras pessoas que podem gerar "falsas memórias", além da influência decorrente de fatores, como, por exemplo, o tempo em que a vítima esteve exposta ao delito e ao agressor; o trauma gerado pela gravidade do fato; o tempo decorrido entre o contato com o autor do delito e a realização do reconhecimento; as condições ambientais (tais como visibilidade do local no momento dos fatos); estereótipos culturais (como cor, classe social, sexo, etnia etc.).

5. Diante da falibilidade da memória seja da vítima seja da testemunha de um delito, tanto o reconhecimento fotográfico quanto o reconhecimento presencial de pessoas efetuado em sede inquisitorial devem seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, de maneira a assegurar a melhor acuidade possível na identificação realizada. Tendo em conta a ressalva, contida no inciso II do art. 226 do CPP, a colocação de pessoas semelhantes ao lado do suspeito será feita sempre que possível, devendo a impossibilidade ser devidamente justificada, sob pena de invalidade do ato.

6. O reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

7. Caso concreto: situação em que a autoria de crime de roubo foi imputada ao réu com base exclusivamente em reconhecimento fotográfico e pessoal efetuado pela vítima em sede policial, sem a observância dos preceitos do art. 226 do CPP, e muito embora tenha sido ratificado em juízo, não encontrou amparo em provas independentes. Configura induzimento a uma falsa memória, o fato de ter sido o marido da vítima, que é delegado, o responsável por chegar à primeira foto do suspeito, supostamente a partir de informações colhidas de pessoas que trabalhavam na rua em que se situava a loja assaltada, sem que tais pessoas jamais tenham sido identificadas ou mesmo chamadas a testemunhar. Revela-se impreciso o reconhecimento fotográfico com base em uma única foto apresentada à vítima de pessoa bem mais jovem e com traços fisionômicos diferentes dos do réu, tanto mais quando, no curso da instrução probatória, ficou provado que o réu havia se identificado com o nome de seu irmão. Tampouco o reconhecimento pessoal em sede policial pode ser reputado confiável se, além de ter sido efetuado um ano depois do evento com a apresentação apenas do réu, a descrição do delito demonstra que ele durou poucos minutos, que a vítima não reteve características marcantes da fisionomia ou da compleição física do réu e teve suas lembranças influenciadas tanto pelo decurso do tempo quanto pelo trauma que afirma ter sofrido com o assalto.

8. Tendo a autoria do delito sido estabelecida com base unicamente em questionável reconhecimento fotográfico e pessoal feito pela vítima, deve o réu ser absolvido.
9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para absolver o paciente.
(STJ - HC: 652284 SC 2021/0076934-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021)

Em resumo, percebe-se que os tribunais superiores passaram a adotar maior cautela com os reconhecimentos feitos por vítimas, exigindo que o trâmite previsto em lei seja preservado ao menos em seu núcleo essencial, e que, além disso, haja no processo outras provas que possam corroborar o reconhecimento.

Essa exigência de um maior rigor procedimental é explicada pela alta falibilidade do reconhecimento como meio de prova, conforme explicado no paradigmático voto do Min. Relator Rogério Schietti Cruz (HABEAS CORPUS Nº 598.886 - SC, julgado em 27.10.2020), citado no julgado acima colacionado.

No referido voto, o Ministro afirma que "o valor probatório do reconhecimento, portanto, deve ser visto com muito cuidado, justamente em razão da sua alta suscetibilidade de falhas e distorções. Justamente por possuir, quase sempre, um alto grau de subjetividade e de falibilidade é que esse meio de prova deve ser visto com reserva".

Vejamos a ementa:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE PESSOA REALIZADO NA FASE DO INQUÉRITO POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. RIGOR PROBATÓRIO.

NECESSIDADE PARA EVITAR ERROS JUDICIÁRIOS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Segundo estudos da Psicologia moderna, são comuns as falhas e os equívocos que podem advir da memória humana e da capacidade de armazenamento de informações. Isso porque a memória pode, ao longo do tempo, se fragmentar e, por fim, se tornar inacessível para a reconstrução do fato. O valor probatório do reconhecimento, portanto, possui considerável grau de subjetivismo, a potencializar falhas e distorções do ato e, conseqüentemente, causar erros judiciais de efeitos deletérios e muitas vezes irreversíveis.

3. O reconhecimento de pessoas deve, portanto, observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se vê na condição de suspeito da prática de um crime, não se tratando, como se tem compreendido, de "mera recomendação" do legislador. Em verdade, a inobservância de tal procedimento enseja a nulidade da prova e, portanto, não pode servir de lastro para sua condenação, ainda que confirmado, em juízo, o ato realizado na fase inquisitorial, a menos que outras provas, por si mesmas, conduzam o magistrado a convencer-se acerca da autoria delitiva. Nada obsta, ressalve-se, que o juiz realize, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório.

4. O reconhecimento de pessoa por meio fotográfico é ainda mais problemático, máxime quando se realiza por simples exibição ao reconhecedor de fotos do conjecturado suspeito extraídas de álbuns policiais ou de redes sociais, já previamente selecionadas pela autoridade policial. E, mesmo quando se procura seguir, com adaptações, o procedimento indicado no Código de Processo Penal para o reconhecimento presencial, não há como ignorar que o caráter estático, a qualidade da foto, a ausência de expressões e trejeitos corporais e a quase sempre visualização apenas do busto do suspeito podem comprometer a idoneidade e a confiabilidade do ato.

5. De todo urgente, portanto, que se adote um novo rumo na compreensão dos Tribunais acerca das consequências da atipicidade procedimental do ato de reconhecimento formal de pessoas; não se pode mais referendar a jurisprudência que afirma se tratar de mera recomendação do legislador, o que acaba por permitir a perpetuação desse foco de erros judiciários e, conseqüentemente, de graves injustiças.

6. É de se exigir que as polícias judiciárias (civis e federal) realizem sua função investigativa comprometidas com o absoluto respeito às formalidades desse meio de prova. E ao Ministério Público cumpre o papel de fiscalizar a correta aplicação da lei penal, por ser órgão de controle externo da atividade policial e por sua ínsita função de custos legis, que deflui do desenho constitucional de suas missões, com destaque para a “defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, da Constituição da República), bem assim da sua específica função de “zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos [inclusive, é claro, dos que ele próprio exerce] [...] promovendo as medidas necessárias a sua garantia” (art. 129, II).

7. Na espécie, o reconhecimento do primeiro paciente se deu por meio fotográfico e não seguiu minimamente o roteiro normativo previsto no Código de Processo Penal. Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheu a autoridade policial fotos de um suspeito que já cometera outros crimes, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o roubo investigado.

8. Sob a égide de um processo penal comprometido com os direitos e os valores positivados na Constituição da República, busca-se uma verdade processual em que a reconstrução histórica dos fatos objeto do juízo se vincula a regras precisas, que assegurem às partes um maior controle sobre a atividade jurisdicional; uma verdade, portanto, obtida de modo “processualmente admissível e válido” (Figueiredo Dias). (...)

12. Conclusões:

1) O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime;

2) À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita e não poderá servir de lastro a eventual condenação, mesmo se confirmado o reconhecimento em juízo;

3) Pode o magistrado realizar, em juízo, o ato de reconhecimento formal, desde que observado o devido procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da autoria delitiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento;

4) O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

No voto condutor, Schietti faz minuciosa análise do problema das falsas memórias e exemplifica à exaustão casos de erros judiciários baseados em reconhecimentos equivocados:

“Estudos apontam que o reconhecimento equivocado (mistaken eyewitness identification) tem sido uma das principais causas de erro judiciário, com a consequência – deletéria e muitas vezes irreversível, diga-se – de levar pessoas inocentes à prisão. Dada a evidência de muitos casos de erros judiciários, foi criada nos Estados Unidos, em 1992, a Innocence Project, uma ONG fundada por advogados civilistas, especialistas em pedir indenização ao Estado em decorrência de condenações de pessoas inocentes. Segundo pesquisa feita por essa ONG, aproximadamente 75% das condenações de inocentes se deve a erros cometidos pelas vítimas e por testemunhas ao identificar os suspeitos no ato do reconhecimento. Em 38% dos casos em que houve esse erro, várias testemunhas oculares identificaram

incorretamente o mesmo suspeito inocente. (Disponível em: www.innocenceproject.org/.../What_is_the_innocence_Project_How_did_it_get_started.php. Acesso em: set. 2020).

Em 2019, o National Registry of Exonerations – banco de dados que reúne a maior quantidade de informações sobre os casos de erros judiciais já revertidos nos Estados Unidos – apontou que as causas mais frequentes de condenação de inocentes naquele país são: falsa acusação (59%); má atuação das autoridades (54%); erro de reconhecimento – terceiro lugar, representando 29% dos casos (INNOCENCE PROJECT BRASIL. Prova de reconhecimento e erro judiciário. São Paulo. 1. ed., jun. 2020, p. 1).

Os exemplos erros de reconhecimento no Brasil também não são poucos. Cito alguns, apenas para ilustrar algo que se repete com relativa frequência na crônica judiciária.

Em 2014, o ator Vinícius Romão de Souza foi preso, após haver sido reconhecido por uma mulher que o acusou de tê-lo assaltado. Depois de permanecer 16 dias na prisão, a 33ª Vara Criminal do Rio de Janeiro concedeu habeas corpus em favor do acusado, depois que a vítima afirmou, em novo depoimento, que se enganou ao fazer o reconhecimento do ator como o suposto autor do delito.

Reporto, também, o caso de André Luiz Medeiros Biazucci Cardoso, que ficou preso por 6 meses e 26 dias, entre outubro de 2013 e maio de 2014, por sete estupros que não cometeu. Aos 27 anos de idade, foi recolhido no Presídio de Bangu, após uma das vítimas do abuso haver anotado a placa do carro dele e entregue à polícia, afirmando ser o veículo do criminoso. Na delegacia, algumas das vítimas reconheceram André como o estuprador, que chegou a ficar 37 dias na "solitária", sem nenhum tipo de contato exterior. A absolvição, com a consequente liberdade, veio depois de o seu advogado conseguir autorização para feitura de DNA nos resíduos biológicos presentes nas vítimas e nas cenas dos crimes, enquanto ele estava preso. O resultado do teste provou não ser ele o responsável pelos delitos. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no Portal G1: BRITO, Guilherme. 'Aprendi a ter fé', diz inocentado após 7 meses preso por estupros no Rio. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2014/10/aprendi-ter-fe-diz-inocentado-apos-7-meses-presos-por-estupros-no-rio.html>. Acesso em: set. 2020).

Registro, ainda, o recente drama vivido pelo violoncelista Luiz Carlos Justino, jovem de 23 anos, preso por engano no centro de Niterói – RJ em 2/9/2020, por um delito ocorrido em 2017. Segundo a acusação, Justino teria praticado um roubo nesse ano, na companhia de mais três pessoas e com emprego de arma de fogo. A participação do referido indivíduo foi determinada por reconhecimento fotográfico, realizado pela vítima ainda em 2017. Em 5/9/2020, o Juiz de primeiro grau converteu a prisão do acusado em domiciliar: "Em termos doutrinários, o reconhecimento fotográfico é colocado em causa em função de sua grande possibilidade de erro. A psicologia aplicada tem se empenhado em investigar fatores psicológicos que comprometem a produção da memória. Neste ramo, encontramos contribuições que dissecam as variáveis que podem interferir na precisão da memória", escreveu o Magistrado. (Informações obtidas a partir da reportagem publicada no site do Correio Braziliense: Músico negro que teria sido acusado por engano é libertado no Rio. Disponível em:

<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2020/09/4873670-musico-negro-que-teria-sido-acusado-por-engano-e-libertado-no-rio.html>. Acesso em: set. 2020)

Faço menção, também, ao caso de Douglas Moreira, que foi preso em janeiro de 2014 – ao voltar para casa depois de plantão realizado no hospital Pan-Americano, na Tijuca, zona norte do Rio de Janeiro –, sob a acusação de roubar um carro em Nova Iguaçu, a 39 quilômetros dali. Policiais retiraram uma foto do auxiliar de serviços gerais do seu perfil no Facebook e apresentaram à vítima que, equivocadamente, o reconheceu como sendo o autor do delito (Disponível em:

<https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/09/20/vida-travadapreso-com-base-em-foto-inocente-fica-ate-3-anos-na-cadeia.htm>. Acesso em: set. 2020).

Por derradeiro, e sem nenhuma pretensão de esgotar os diversos exemplos de

afirmados erros de reconhecimento, registro o recente caso de Lucas Moreira de Souza, que chegou a ser condenado a quase 80 anos de prisão, por suposto envolvimento em uma série de assaltos. A Justiça do Distrito Federal, há poucos dias, reverteu a condenação, em razão das inconsistências na investigação: a única prova apresentada contra o então suspeito era um reconhecimento impreciso feito por testemunhas (Disponível em: <https://g1.globo.com/df/distrito-federal/noticia/2020/10/21/jovem-de-27-anos-e-absolvido-apos-ficar-quase-3-anos-presos-por-crimes-que-nao-cometeu-no-df.ghtml>. Acesso em: out. 2020)".

Diante de tudo quanto afirmado acima, em conclusão, não se pretende desconsiderar por completo qualquer procedimento baseado na memória como meio de prova, até porque o processo penal brasileiro se escora principalmente nas provas testemunhais.

O que se pretende demonstrar, apenas, é que reconhecimentos nem sempre são totalmente confiáveis, e justamente por isso, devem seguir o procedimento previsto no art. 226 do CPP e, além disso, ser confirmados por outras provas.

No caso em análise, o procedimento de reconhecimento já se mostra frágil, afinal, foi feito por álbum de fotografias.

Não bastasse, as vítimas teriam visto o assaltante por um período muito rápido, alguns poucos segundos, enquanto o criminoso guiava um veículo e ligava, contra os observadores, o farol alto. Tal fato chama atenção, afinal, é de conhecimento comum que ao se deparar com um veículo com farol alto no sentido contrário, a visibilidade tende a ser prejudicada, e não beneficiada. Assim, difícil imaginar que as vítimas teriam, nessas circunstâncias, conseguido visualizar com clareza o assaltante para, posteriormente, reconhecê-lo sem sombra de dúvidas em uma única fotografia.

E aqui é importante que se diga que não se está, de forma alguma, afirmando que as vítimas teriam propositalmente tentado prejudicar o réu, muito pelo contrário. É certo que as vítimas sofreram sérios abalos emocionais em virtude do grave crime que sofreram, e, justamente por isso, seriam os maiores interessados em ver punido o verdadeiro agressor. Contudo, pelas circunstâncias já narradas, há pouca segurança sobre o reconhecimento feito em solo policial, razão pela qual necessitaria ser corroborado por outros elementos, o que não se verificou no caso concreto.

Como já dito, não foi apreendido com o réu nenhum objeto relativo a qualquer roubo, as imagens da câmera de segurança do condomínio não foram juntadas aos autos, não houve, ao menos no presente processo, qualquer investigação que o ligasse com outros integrantes da suposta quadrilha que assaltava advogados.

Enfim, não há nos autos nenhuma outra prova que possa confirmar o reconhecimento feito pelas vítimas, que, conforme extensamente explicado acima, não possui a confiança necessária para superar o standard probatório exigido para a condenação, de modo que a absolvição é de rigor.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido para ABSOLVER o réu JEFFERSON MENDES MARQUES DA SILVA das acusações que lhe foram feitas na denúncia, nos termos do art. 386, VII, CPP.

Expeçam-se as certidões de honorários advocatícios nos termos do Convênio DPE/OAB para essa espécie processual.

Oportunamente, arquivem-se.

Cópia da presente, assinada digitalmente, servirá como mandado/carta precatória/alvará/ofício/termo para as finalidades cabíveis, lembrando-se que a sua autenticidade poderá ser confirmada no endereço eletrônico do E. TJSP (www.tjsp.jus.br).

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Itapeccerica da Serra, 25 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA